

1500237-76.2022.8.26.0296

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO FORLI FORTUNA

Comarca: Jaguariúna

Foro: Foro de Jaguariúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... que, para a configuração do delito de tráfico é preciso que a acusação logre êxito em demonstrar não só a materialidade e a autoria delitiva, mas também que a droga era destinada ao tráfico.

Isso porque, o tipo penal é claro ao exigir que a droga apreendida seja destinada ao comércio espúrio. Aliás, é isso que diferencia o delito de tráfico do delito de uso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaguariúna

Foro de Jaguariúna

1ª Vara

Rua Santo Antonio de Posse, 259, Jaguariuna - SP - cep 13911-016

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500237-76.2022.8.26.0296 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500237-76.2022.8.26.0296

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLAYTON DOS REIS DOMINGUES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO FORLI FORTUNA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial (fl. 4-56), ofereceu denúncia contra CLAYTON DOS REIS DOMINGUES, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (fl. 1-2).

Alegou que, no dia 8 de março de 2022, por volta de 23h55, na Rua Pedro Maion, 343, nesta cidade e Comarca, o réu trazia consigo 34 porções de cocaína, pesando 0,26g, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narrou que, por ocasião dos fatos, o réu estava em local conhecido como ponto de tráfico, quando guardas municipais o avistaram dispensando algo ao solo. Diante da atitude suspeita, realizaram a abordagem e com ele encontraram 20 reais. Em busca no objeto dispensado, verificaram se tratar de um embrulho contendo 34 pinos de cocaína.

Sustentou que as circunstâncias e o local da prisão em flagrante, a quantidade e

forma de embalagem dos entorpecentes, aliados à apreensão de dinheiro levam à conclusão de que o denunciado trazia consigo a droga apreendida para consumo de terceiros.

O denunciado foi preso em flagrante (fl. 5-6) e teve a prisão convertida em preventiva (fl. 57-60).

O réu foi notificado (fl. 99) e apresentou defesa prévia (fl. 103-105).

A denúncia foi recebida e foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 111-113).

O réu foi citado (fl. 124).

Em audiência, duas testemunhas arroladas pela acusação foram ouvidas, sendo, após, o réu interrogado. Ao final as partes apresentaram alegações finais orais. A acusação postulou pela procedência do pedido para condenar o réu nos termos da denúncia, observando-se a reincidência para elevar a pena base e para impedir a aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A defesa postulou, preliminarmente, pela ilicitude da prova obtida, uma vez que obtida por meio de atividade de policiamento ostensivo pela guarda municipal, não tendo ela competência para realizar busca pessoal nos casos em que não se vinculem as suas atividades finais de preservação de bens, de serviços e de instalações municipais ou para assegurar a adequada execução do serviço municipal, conforme Resp 1.977.119 do STJ. No mérito, postulou pela desclassificação para o crime de posse ou porte de drogas para consumo pessoal (fl. 127).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, observo que não há qualquer vício capaz de inquinar de nulidade a presente ação penal, tendo sido observado adequadamente o rito especial previsto na Lei de Drogas, bem como garantidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório em favor do réu.

Ademais, a preliminar de ilicitude da prova da materialidade arguida pela defesa não merece prosperar, uma vez que a situação fática analisada nestes autos se diferencia da analisada no Resp 1.977.119.

Com efeito, naqueles autos, houve apreensão de drogas por guardas municipais após busca pessoal feita no réu, sendo declarada a ilicitude da prova por violação ao art. 244 do CPP.

No caso destes autos, como se verá no decorrer da fundamentação desta decisão, o réu foi abordado por guarda municipais após ter jogado ao solo um saco com drogas. Nesse sentido, constou no corpo do referido julgado do STJ :

Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.

No caso, os guardas viram a dispensa da droga e, em seguida abordaram o réu.

Note-se a distinta situação do julgado, no qual o indivíduo guarda a droga em seus pertences.

Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito. Desse modo, não há que se falar em ilicitude da prova, uma vez que as drogas foram encontradas pelos guardas municipais no chão após o réu as ter dispensado.

No mais, a pretensão punitiva deduzida em juízo é procedente, vejamos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processo a responsabilidade criminal do réu, anteriormente qualificado, pela

prática do delito tipificado no artigo 33, "caput", da Lei de 11.343/2006, o qual assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Inicialmente, veja-se que, para a configuração do delito de tráfico é preciso que a acusação logre êxito em demonstrar não só a materialidade e a autoria delitiva, mas também que a droga era destinada ao tráfico.

Isso porque, o tipo penal é claro ao exigir que a droga apreendida seja destinada ao comércio espúrio. Aliás, é isso que diferencia o delito de tráfico do delito de uso de drogas.

É importante ressaltar que para concluirmos se a droga é ou não destinada ao tráfico é imprescindível cotejarmos os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo artigo 52, I da Lei 11.343/06, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão e d) conduta e antecedentes do agente.

Feita essa breve incursão teórica, passemos ao estudo das provas carreadas nos autos, cotejando-as com os fatos descritos na denúncia, para concluirmos sobre a autoria e responsabilidade do réu.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 5-6), pelo boletim de ocorrência (fl. 8-10), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 13), pelo laudo pericial (fl. 93-95) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A existência do crime, portanto, é certa.

Do mesmo modo, a autoria e a responsabilidade do réu foram comprovadas pelas provas carreadas nos autos. Vejamos.

Interrogado em juízo, o acusado negou os fatos. Afirmou que o primeiro guarda municipal que se apresentou estava no momento da abordagem, mas o segundo não. Eles estavam em três dentro da viatura. Quando o abordaram, perguntaram se tinha droga, confirmou que tinha três pinos. Apresentou a eles. Os guardas pegaram os três pinos e disseram que iriam procurar mais. Disse que tinha três câmeras no local e sua casa fica a 100 metros do local. Nunca foi abordado no local da prisão. Estava em Minas há doze anos. Veio para Jaguariúna no final do ano. Não estava na cidade há doze anos, desde 2012, quando foi a primeira vez preso. Os guardas falaram que iriam levá-lo para a delegacia para fazer como usuário e ver o que o delegado iria fazer. Não o algemaram, não foram agressivos. Tem problema crônico de cocaína. Voltou para Jaguariúna para se tratar com a ajuda de seu pai. Estava trabalhando registrado no Bonneto no período das 7 da manhã às 16 da tarde. Usa droga todos os dias. Não fica com dinheiro. Usa apenas cartão. Tinha dinheiro no dia para comprar remédio. A biqueira fica no caminho de sua casa e precisa passar por ela. Nunca foi abordado pelos guardas municipais. Foi preso anteriormente porque invadiram a casa de um colega seu e foram presos, mas foi absolvido em audiência. Foi condenado anteriormente há um ano e oito meses, mas não sabia que era por causa do tráfico. Conhece o primeiro guarda desde 2012, mas o segundo nunca viu. Não tem problema com os guardas. Trabalhava registrado no boneto e, por causa do uso de drogas, estava quase dando como abandono de trabalho. Falaram que não iriam renovar o trabalho. Quando o prenderam, ainda não tinha dado baixa em sua carteira de trabalho. Estava há cerca de quinze dias sem aparecer no trabalho quando de sua prisão. Estava muito fraco e na cama. Recebia cerca de R\$ 1.090,00 por mês. No dia da prisão, comprou três pinos por R\$ 30,00, um soro para o nariz e um corote de pinga. Estava com uma nota de R\$ 20,00 no momento da prisão.

Em que pese a tentativa do réu em se eximir de sua responsabilidade penal, tal versão não se sustenta, uma vez que encontra-se isolada nos autos, não tendo sido corroborada pelas demais provas colhidas na persecução penal.

Pelo contrário, o réu foi preso em flagrante delito e os guardas municipais que efetuaram a prisão ratificaram, em juízo, seus depoimentos prestados na fase de investigações preliminares, indicando de forma precisa o réu como autor do crime. Nesse sentido, a testemunha arrolada pela acusação, o guarda municipal Jason Altino de Lima, ouvido em juízo, confirmou que prendeu o réu em flagrante. Estavam em patrulhamento pelo bairro Florianópolis, em local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes. Avistaram o indivíduo, que ao avistar a viatura, jogou algo. Na abordagem, foi encontrado no bolso dele uma nota de R\$ 20,00 e seu documento. Após verificar o que ele jogou, o embrulho esparramou 34 pinos de cocaína todos semelhantes. Indagado, o réu justificou que jogou só três e que o restante não era dele. A visibilidade do local é boa. A iluminação era artificial porque estava noite, mas era boa a visibilidade. Já conhecia o réu dos meios policiais. Já efetuaram prisões de outros traficantes no local em que o réu foi preso. Presenciou o momento que o réu arremessou o pacote que trazia nas mãos. Era um embrulho plástico. Quando o réu jogou, o pacote abriu e se esparramou. Era parecido com uma sacola de supermercado. Já tinha visto o réu no local de sua prisão mais vezes. Ele estava sozinho no local. Tem conhecimento que o réu já foi preso por tráfico em outro bairro da cidade, estando presente no momento daquela prisão. Isso foi há alguns anos atrás. No momento da prisão, o réu falou que era usuário de drogas. Não abordou o réu portando drogas, apenas teve conhecimento de que o réu já tinha sido preso por tráfico de drogas porque estava de serviço no dia da prisão.

Corroborando o depoimento da testemunha anterior, a outra testemunha arrolada pela acusação, o guarda municipal Valdenir da Silva Pereira, em juízo, prestou depoimento no mesmo sentido, narrando que prendeu o réu por tráfico de drogas. Estavam em patrulhamento pelo bairro Florianópolis, quando passaram pela rua Pedro Maion, próximo a um local que estava tendo ponto de venda de drogas, e avistaram o réu na calçada. Quando o réu viu a viatura, dispensou algo ao lado dele. Abordaram o réu, localizaram no bolso R\$ 20,00. Onde ele jogou o embrulho de plástico, foi localizado 34 pinos de cocaína. Foi localizado no chão porque o réu jogou no chão. Na maioria das vezes é encontrado com o indivíduo porque não dá tempo da pessoa jogar quando é surpreendido. A visibilidade no local era boa. Alguns dias antes, já avistou o réu naquele local, mas ele correu quando avistou a viatura e não foi capturado. O réu já foi abordado outras vezes, mas não encontrado drogas naquelas ocasiões. Não sabe onde o réu mora.

É importante salientar que, em delitos de tráfico de drogas, cometidos em sua maioria na clandestinidade, a prova, em regra, se resume aos depoimentos dos agentes de segurança (policiais e guardas municipais).

Aliás, não haveria como ser diferente, uma vez que são os referidos policiais que têm a importante função de patrulhar diariamente as ruas das cidades, coibindo práticas ilegais, garantindo a ordem e a segurança pública.

Assim, desde que prestados de forma pormenorizada, com segurança e em harmonia, os depoimentos dos policiais são suficientes para ensejar a condenação do réu.

Nesse contexto, as informações trazidas pelos policiais encontram-se coerentes e em harmonia com os demais elementos probatórios constantes nos autos em relação ao fato das drogas apreendidas estarem com o réu no momento de sua abordagem, tendo eles descrito de modo claro a ocorrência no dia do acontecimento. Além disso, o réu foi categórico ao afirmar em seu interrogatório que tem problemas com os guardas municipais que efetuaram sua prisão. Dessa forma, os depoimentos dos guardas municipais merecem credibilidade, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório.

Portanto, ficou cabalmente provada a autoria do réu, uma vez que ele foi capturado por guardas municipais trazendo consigo 34 pinos de cocaína na data e no local constantes na denúncia.

No mais, além de provadas a materialidade e autoria delitiva, restou bem demonstrado que a droga era destinada ao comércio.

Com efeito, o réu foi preso em flagrante delito em local conhecido no meio policial como ponto de venda de tráfico de drogas trazendo consigo 34 pinos de cocaína e o valor de R\$ 20,00. A quantidade fracionada das drogas apreendidas com o réu, bem como a forma que estavam embaladas, indicam que elas eram destinadas à venda. Além

disso, o réu é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, conforme pode ser constatado de sua folha de antecedentes criminais de folhas 39-41. Outrossim, a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347). Dessa forma, ficou cabalmente comprovada a mercancia da droga.

Noutro giro, em seu interrogatório, exercendo seu direito a autodefesa, o réu alegou que apenas três pinos de cocaína eram seus e que os guardas municipais teriam implantado os demais pinos no flagrante. Contudo, não há nos autos qualquer elemento que comprove a ocorrência desse fato. Veja que o réu, em seu interrogatório, disse que havia três câmeras de monitoramento no local em que foi preso em flagrante, mas não indicou o nome de possíveis estabelecimentos comerciais para que fosse possível proceder a diligências para apreensão de alguma filmagem da ação, nem a defesa requereu tais diligências. Desse modo, a alegação feita pelo réu não merece prosperar, uma vez que o réu não se desincumbiu de seu ônus de provar o que alega nos termos do art. 156 do CPP.

Ainda, não prosperam as alegações da defesa de que as drogas portadas pelo acusado destinavam-se ao consumo pessoal. Isso porque, em especial por conta da quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas – incompatíveis com situação de posse de drogas para uso pessoal, apesar de arguido pelo acusado –, ocorre que o réu jamais logrou comprovar, por qualquer meio lícito em Direito, sua suposta condição de toxicodependente.

Lado outro, não chega a ser incomum, mesmo nos casos de comprovada situação de usuário de drogas, o enredamento de usuários no comércio varejista de drogas, invariavelmente em troca de acesso facilitado aos entorpecentes, que, por seu turno, passa a ser arregimentado pela célula criminosa do tráfico, em atuação direta junto aos demais usuários.

É esta uma das muitas estratégias do crime para tentar burlar a ação repressiva do Estado, mascarando a atividade comercial por meio da cooptação de usuários contumazes ou dependentes químicos. Daí não se cogitar de aperfeiçoamento distinto, na espécie, senão pelo crime de tráfico de drogas, eis que presentes todos os elementos configuradores.

Nesse sentido, confira-se:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Apelo defensivo pela absolvição por fragilidade probatória e desclassificação para o crime de consumo pessoal de entorpecentes. Descabimento no mérito. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, e exame toxicológico definitivo. Existência comprovada dos fatos apurados. Harmonia entre os testemunhos dos policiais. Testemunho defensivo incoerente e vago. Circunstâncias do flagrante que se viram coonestadas na instrução. Ausência de respaldo probatório ou plausibilidade. Devido aperfeiçoamento de condutas nucleares. Condenação mantida. Redimensionamento punitivo que aqui se opera de ofício, com parcial abrandamento das penas. Parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1501066-43.2020.8.26.0291; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaboticabal - Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/10/2021; Data de Registro: 15/10/2021)

Tráfico de drogas. Maconha. Condenação em Primeiro Grau. Absolvição ou desclassificação das condutas. Impossibilidade. Materialidade e autoria certas. Réu flagrado com significativa quantidade de droga, em montante incompatível com o alegado consumo pessoal. Incriminador depoimento de policiais militares. Negativa isolada. Condenação mantida. Penas. Básica que deve ser fixada no mínimo legal. Afastamento da reincidência. Necessidade. Primariedade reconhecida. Consequente redução da pena fundada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e regime aberto. Provimento

parcial do apelo defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 1500101-76.2021.8.26.0567; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Votorantim - Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 07/10/2021)

Finalmente, concluindo pela tipicidade do fato, da mesma forma verifica-se sua ilicitude. Isso porque não se faz presente qualquer causa excludente de antijuridicidade, quais sejam, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal. A conduta do acusado, além de típica, contraria o ordenamento jurídico pátrio, atingindo bens constitucionalmente tutelados.

Ainda, não se faz presente qualquer causa que afaste a culpabilidade do réu, sendo o mesmo imputável, apresentando potencial consciência de ilicitude, podendo-se esperar conduta diversa da praticada.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar o réu CLAYTON DOS REIS DOMINGUES, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

Analisando as diretrizes traçadas pelos artigos 59, do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. O réu é possuidor de maus antecedentes (fl. 39-41), todavia deixo para valorá-los na segunda fase de dosimetria da pena por se tratar de reincidência (Súmula 241 do STJ). Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado; o motivo do crime é identificável como o desejo de obtenção de renda fácil. As consequências do crime são desconhecidas, sendo suas circunstâncias neutras, uma vez que não foi vislumbrada uma quantidade extraordinária de tóxicos e tampouco o acusado depreendeu um modus operandi anormal à espécie criminal em evidência. Não há que falar, neste caso, em comportamento da vítima.

Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 05 (cinco) de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência, uma vez que o réu já foi condenado por crime idêntico, conforme sua folhas de antecedentes criminais de folhas 39-41.

Assim, aumento a pena intermediária em 1/6 e a fixo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. Isso porque o réu é reincidente, o que impede a incidência da diminuição do tráfico privilegiado, tipificado no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Assim, fixo definitivamente a pena para o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, considerando a reincidência específica e a equiparação do crime de tráfico ao hediondo, é caso de imposição de regime inicial fechado.

Inadmissível ainda a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como concessão de suspensão condicional da pena, uma vez que não se fazem presentes os requisitos objetivos para a concessão dos referidos benefícios.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, sendo tal medida necessária para a manutenção da ordem pública, diante dos maus antecedentes do preso e da gravidade dos crimes, bem como a garantia da aplicação da Lei penal, ainda mais com a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena do crime apurado nestes autos.

Disposições finais:

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão para os efeitos do artigo

15, III da Constituição Federal;
Oficie-se a Secretaria Nacional Antidroga SENAD, na forma do § 4º do art. 63 da Lei 11.343/06, comunicando sobre a perda do numerário supra.
Providencie-se a incineração do material tóxico apreendido, lavrando o devido auto.
Expeça-se certidão de honorários, se for o caso.
P.R.I.C.

Jaguariuna, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA